



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Dictamen firma conjunta

Número:

Referencia: OPI 297 - Archivo

SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO

Elevamos a su consideración el presente dictamen referido a las actuaciones que tramitan bajo Expediente N° EX-2017-17119241- -APN-DDYME#MP caratulado: “OPI N° 297 - LA RURAL S.A. - OFC S.R.L. - OGDEN ARGENTINA S.A.-ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNION TRANSITORIA S/ CONSULTA INTERPRETACIÓN LEY N° 25156” del registro del MINISTERIO DE PRODUCCION, e iniciadas en virtud de la consulta promovida en los términos del Artículo 8° del Decreto PEN N° 89/2001, reglamentario de la Ley N° 25.156 por parte de la UNION TRANSITORIA formada por LA RURAL S.A. – OFC S.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. – ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A (en adelante denominada la “UT”).

I. SUJETOS INTERVINIENTES Y SU ACTIVIDAD

I.1. Por la Compradora

1. LA RURAL S.A. (en adelante denominada “LRSA”), OFC S.R.L. (en adelante denominada “OFC”), OGDEN ARGENTINA S.A. (en adelante denominada “OASA”) Y ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. (en adelante denominada “ENUSA”) conformaron la UT en los términos del Art. 1463 y siguientes del Código Civil y Comercial de la Nación con las siguientes participaciones: LRSA: 5%; OFC: 20%; OASA: 55%; ENUSA: 20%.

2. Conforme lo han informado las consultantes, el mecanismo decisorio en la UT será por mayoría absoluta de acuerdo al porcentaje de participación de cada miembro y siempre que al menos dos de los miembros voten conforme el voto de la mayoría. La supervisión y dirección general de las operaciones de la UT estará a cargo de un Comité Ejecutivo compuesto por un representante de cada uno de los miembros.

3. LRSA es una sociedad que tiene por actividad principal la explotación del Predio Ferial de Buenos Aires, ubicado entre las Avenidas Cerviño, Sarmiento, Santa Fe y la calle Oro, de la Ciudad de Buenos Aires.

4. Los accionistas de LRSA son OASA con una participación del cincuenta por ciento (50%) de las acciones ordinarias y de los votos de LRSA y del cien por ciento (100%) de las acciones preferidas de LRSA y La Rural de Palermo S.A. (“LRP”), titular del restante cincuenta por ciento (50%) de las acciones ordinarias y de los votos de LRSA. La única actividad de ambas sociedades consiste en ser titular de dichas acciones.

5. LRSA no posee sociedades controladas. Sin perjuicio de ello, tiene participaciones en dos sociedades: i) CENTRO INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN EN TECNOLOGÍA AGROPECUARIA S.A., sociedad cuya actividad principal se basa en organizar anualmente la feria denominada CITA, sobre maquinaria y tecnología agropecuaria, feria que tiene lugar en el Predio de La Rural. LRSA tiene en esta sociedad una participación del 50%; y ii) EXPOSICIONES Y FERIAS DE LA CONSTRUCCIÓN ARGENTINA S.A., sociedad cuya actividad principal consiste en organizar anualmente la feria denominada Expovivienda en el Predio de La Rural, dedicada al mercado de la construcción. LRSA tiene en esta sociedad una participación del 33.50%.

6. OASA es una sociedad cuya única actividad consiste en ser titular de acciones representativas del cincuenta por ciento (50%) de las acciones ordinarias y de los votos de LRSA y del cien por ciento (100%) de las acciones preferidas de LRSA. La sociedad controlante de OASA es Boulevard Norte (“BN”), titular de las acciones representativas del noventa y cinco por ciento del capital y votos de OASA. La actividad principal de BN se desarrolla en los rubros de inversión, construcción, inmobiliario y financiero.

7. ENUSA es una sociedad que tiene como actividad principal realizar ciertos eventos en el Predio de La Rural de Palermo. La sociedad controlante de ENUSA es ENTERTAINMENT HOLDINGS S.A., titular de acciones representativas del noventa y cinco por ciento (95%) del capital y votos de ENUSA. Su única actividad consiste en ser titular de dichas acciones a su vez, ENUSA controla a las sociedades BN, OASA y LRSA.

8. LRSA, OASA y ENUSA se encuentran controladas en última instancia por IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A, sociedad que tiene como actividad principal, directa o indirectamente a través de sus subsidiarias, la locación de espacios y administración de centros comerciales, la emisión y comercialización de tarjetas de crédito, y la construcción y venta de inmuebles.

9. OFC tiene por actividad principal brindar servicios integrales para eventos, congresos, convenciones y exposiciones. OFC no posee sociedades controladas o controlantes.

I.2 Por la Concesionaria

10. GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES (en adelante “GCBA”), actuando a través de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DEPENDIENTE del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA.

I.3 Por el Objeto

11. La operación objeto de consulta lo constituye el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Av. Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y Dr. Carlos Vaz Ferreira (en adelante “CECCBA”) por cuanto se trata únicamente de un inmueble de titularidad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

II. LA OPERACIÓN SUJETA A CONSULTA

12. La operación sujeta a consulta se produjo con fecha 4 de agosto de 2017, en donde se suscribió el Contrato de Concesión, entre la UT y el GCBA, en virtud del cual se otorgó a la UT la concesión para el uso y la explotación del predio, donde se ubica el CECCBA (en adelante la “Concesión”).

13. Informaron las partes que el objeto de la Concesión es el uso y la explotación del CECCBA para el desarrollo por parte de la UT de actividades de gerenciamiento, comercialización, programación y realización de reuniones, entendido como eventos, reuniones gubernamentales, de empresas y de asociaciones, viajes de incentivos de empresas, seminarios, congresos, conferencias, convenciones entre otros, todo ello conforme las definiciones establecidas en los Pliegos que rigen la Concesión.

14. El plazo de la Concesión se fijó en quince (15) años contados desde la entrega del CECCBA. Siendo el canon mensual es de pesos un millón cuatrocientos once mil cuatrocientos uno (\$ 1.411.401) estableciendo para los primeros cinco años un esquema de pagos reducidos (25% del canon el primer año, 35% el segundo, 55% el tercero, 80% el cuarto y el 100% a partir del quinto año).

15. Expresaron que la adquisición del inmueble no puede ser considerada como una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6 de la Ley N° 25.156, por cuanto se trata de un contrato por el cual se otorga el uso y explotación por un tiempo limitado de un inmueble en el que no se desarrollan actividades desde el año 2014.

16. Afirman en ese sentido que no se trata de la adquisición del control de una empresa en tanto no se adquiere el control de un activo al que pueda atribuirse un volumen de negocios y una clientela propia.

17. A fin de caracterizar el concepto de activos en el inc. d) del art 6, 1er párrafos han citado jurisprudencia de esta Comisión en la cual se ha afirmado que son activos “todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originando en la posibilidad de asuntos de naturaleza económica” (OPI N°83 DEL 27/12/2000)”.

18. Bajo los argumentos anteriores, las consultantes sostienen que la operación bajo consulta no incluye la transferencia de activos con un volumen de negocios independiente, clientela y valor propios por distintos motivos, entre otros, que: i. se trata de un contrato de concesión por un tiempo limitado de un inmueble sin actividad desde hace años y, por lo tanto, sin volumen de negocios o clientela propios; ii. no se trata de la transferencia de un fondo de comercio o de participación entre las sociedades involucradas en la operación.

19. Explican que se trata de una operación no notificable pues en este caso se trata de una Concesión para la explotación de un inmueble al que el concedente le ha fijado un destino específico que la UT como concesionaria deberá respetar durante el plazo que dure la Concesión y tras el cual deberá reintegrar el inmueble. En consecuencia, no hay transmisión de bienes, y el objeto de la Concesión no son los activos de una empresa ni un fondo de comercio ni una unidad de negocios, sino que se da en concesión un inmueble para su uso y explotación conforme la Concesión.

20. Manifiestan accesoriamente las consultantes que, no obstante, más allá de los fundamentos esgrimidos, si se entendiera que el objeto de la Concesión es un activo y por lo tanto existe una concentración, la operación objeto de la consulta no quedaría alcanzada por la obligación de notificación establecida en el Artículo 8 de la Ley 25.156 por cuanto aplicaría la excepción prevista en el inciso d) del Artículo 10 de la Ley 25.156. Ello en virtud de que la concesión del CECCBA, debería ser asimilada a la adquisición de una empresa en liquidación en tanto no ha tenido actividad por un plazo que supera ampliamente el último ejercicio.

21. Señalan las consultantes que la UT resultó concesionaria del CECCBA como resultado de un proceso licitatorio [público y abierto] que garantiza la transparencia y el marco competitivo adecuado para la participación de todos los interesados en la concesión.

22. Finalmente, las partes manifestaron que con fecha 3 de octubre de 2017, se hizo efectiva la entrega del predio concesionado.

III. EL PROCEDIMIENTO

23. Con fecha día 14 de agosto de 2017 se presentó el apoderado de LA RURAL S.A. – OFC S.R.L. – OGDEN ARGENTINA S.A. – ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNION TRANSITORIA a fin de requerir una opinión consultiva respecto de la obligación de notificar una operación de concentración económica en los términos del Artículo 8° del Decreto N° 89/01 y Resolución SCT N° 26/06.

24. Luego de sucesivos requerimientos y respuestas, con fecha 18 de diciembre 2017 los consultantes

efectuaron una presentación que da respuesta a los requerimientos efectuados por esta Comisión Nacional comenzando a correr a partir del día hábil posterior, el cómputo del plazo establecido en el Artículo 8 del Anexo I del Decreto N° 89/2001 y apartado a.4. del Anexo I de la Resolución SCI N° 26/2006, pasando las actuaciones a dictaminar.

IV. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN PLANTEADA

25. Analizadas las presentaciones efectuadas, resulta necesario aclarar que ésta opinión consultiva reconoce como sustento fáctico estrictamente las circunstancias relatadas en las sucesivas presentaciones. En consecuencia, cualquier omisión o desarrollo que no se ajuste a la presentación y que pudiere implicar una modificación de las condiciones descriptas que se valoran determina la inaplicabilidad de la presente al caso en estudio.

26. Dado que las consultantes expresaron que la concesión del CECCBA no puede ser considerada como una operación de concentración económica en los términos del Artículo 6 de la Ley N° 25.156, por cuanto ésta no incluye la transferencia de activos con un volumen de negocios independiente, clientela y valor propios, se ha de abordar seguidamente la cuestión que consiste en determinar con precisión si la operación consistente el otorgamiento a la UT de la concesión para el uso y la explotación del predio donde se ubica el CECCBA se encontraría exenta de la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la N° 25.156.

27. Habiendo descripto en los apartados anteriores, las principales características de la operación traída a consulta y a la excepción planteada, corresponde en esta instancia expedirse sobre la misma.

28. Previo a todo, debe tenerse en cuenta en la operación bajo análisis que el contrato que da lugar a la concesión del CECBA se encuentra bajo el régimen de los denominados “contratos administrativos”, siendo el acuerdo de voluntades con el contratista privado caracterizado (i) por perseguir una finalidad inmediata de interés público propia de la función administrativa o, si se prefiere, de su tráfico o giro normal; (ii) por contener un régimen típico del derecho administrativo con prerrogativas de poder público y, (iii) por un sistema de selección fundado en los principios de publicidad, igualdad y concurrencia¹. Analizaremos a continuación cada una de las características mencionadas para la operación traída a consulta de esta Comisión Nacional.

29. Respecto de la finalidad u objetivo de interés público, se desprende del Pliego de Bases y Condiciones Particulares la intención del cedente de “Promover el turismo como factor de desarrollo económico, social y cultural, potenciando el aprovechamiento de sus recursos e infraestructura turística”. Que con dicho objetivo el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha creado el Ente de Turismo como autoridad de aplicación.

30. Se visualizan en el instrumento de la operación las prerrogativas del poder público de la autoridad de aplicación al poder establecer sanciones e incluso la rescisión de la concesión frente a determinados incumplimientos del cesionario², que van más allá de cualquier incumplimiento típico establecido en un contrato entre privados, entre otras cuestiones, tal como ser la determinación del nombre de la explotación.

31. He aquí la potestad de control por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no es dable determinar la existencia de control por parte de la UT en los términos del Artículo 6° de la Ley 25.156 en el sentido de permitirle determinar el comportamiento de la empresa, el inmueble en este caso, sobre el cual recae la operación. Es decir, le otorgue una influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria sobre el objeto de la operación.

32. En cuanto a la última característica, la misma se cumple para el caso bajo análisis por cuanto el mecanismo de selección del concesionario se ha hecho por medio de los mecanismos idóneos para tal fin, es decir el llamado a una licitación pública nacional e internacional para la concesión de uso del CECBA, con la correspondiente evaluación de las ofertas recibidas y la subsiguiente adjudicación a la UT.

33. De cara al análisis de la excepción planteada por los consultantes, se recuerda que el Artículo 6° de la Ley N° 25.156 define a las concentraciones económicas como la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de una serie de actos que dicho Artículo enumera. Particularmente, el inciso d) establece: “Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa” es decir, los actos objeto de notificación obligatoria siempre implican de alguna forma la toma de control – sea de iure o de facto- de una, varias empresas o de sus activos.

34. Tal como lo expone la UT en su presentación inicial, esta Comisión Nacional ha manifestado reiteradamente que el concepto de activos contenido en el inc. d) del art. 6 primer párrafo de la Ley 25.156 debe entenderse como: “todos aquellos que permitan el desarrollo de una o varias actividades, a las que se les pueda, además atribuir un volumen de negocios independiente, con clientela y valor propios originado en la posibilidad de asuntos de naturaleza económica”. Esta definición adoptada en la Opinión Consultiva N° 83 del 27 de diciembre de 2000, fue luego tomada en cuenta en gran cantidad de casos similares puestos a consideración de éste Organismo.

35. Siguiendo el criterio de esta Comisión Nacional, una operación no puede ser objeto de notificación en tanto si bien sobre el inmueble objeto se desarrolló algún tipo de actividad comercial, al momento de la operación, el mismo se encuentra desocupado y sin actividad desde el año 2014 por lo que no puede atribuírsele operación comercial, actividad empresarial, ni clientela alguna.

36. No se da para el caso en concreto el “Requisito de Continuidad” que esta Comisión ha establecido a fin de considerar notificable una operación económica cuyo principal objeto lo constituya un bien inmueble, a saber: (i) que el inmueble tenga clientela propia y (ii) que el inmueble continúe utilizándose en la misma actividad que el mismo se venía utilizando.

37. En otras palabras, esta COMISIÓN NACIONAL considera que la cuestión planteada no implica una toma de control de una empresa por parte de UT, en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 25.156. Consecuentemente, la operación traída a consulta no se encuentra alcanzada por la obligación de notificación prevista en el artículo 8° de la Ley N° 25.156.

V.CONCLUSIÓN

38. En base a las consideraciones expuestas en los párrafos que anteceden, esta COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA aconseja al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156. Asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el Expediente de referencia, por lo que, si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos aquí vertidos;

39. Elévese el presente Dictamen al SEÑOR SECRETARIO DE COMERCIO, previo paso por la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN DE LA NACIÓN para su conocimiento.

Se deja constancia que los Sres. Vocales, Dr. Pablo Trevisan y Dra. Fernanda Vicens, no suscriben el presente por encontrarse en uso de licencia.

¹ Cassagne, Juan Carlos. “Sobre la contratación pública” Publicado en: LA LEY 24/06/2013, 24/06/2013, 1 - LA LEY2013-D, 647.

² Ver Capítulos XI y XII del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas aprobado mediante el Decreto 2016-548-AJG de fecha 27 de octubre de 2016.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número:

Referencia: EX-2017-17119241- -APN-DDYME#MP - OPINIÓN CONSULTIVA (OPI 297)

VISTO el Expediente EX-2017-17119241- -APN-DDYME#MP, y

CONSIDERANDO:

Que en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, procedes su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 6° a 16 y 58 de dicha ley.

Que la operación sujeta a consulta fue presentada por la firma LA RURAL S.A., OFC S.R.L., OGDEN ARGENTINA S.A., ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA, el día 14 de agosto de 2017, y consiste en la concesión por la cual se otorgó a dicha Unión Transitoria el uso y la explotación del predio donde se ubica el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, delimitado entre el Parque Thays y la Plaza República Federativa de Brasil, sobre la Avenida Presidente Figueroa Alcorta, entre las calles Julio Víctor González y Doctor Carlos Vaz Ferreira.

Que el día 4 de agosto de 2017, se suscribió un Contrato de Concesión, entre la mencionada Unión Transitoria y el GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, representado por la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO dependiente del MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA, en el cual se estableció el plazo de QUINCE (15) años para el uso y explotación del Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires por parte de la citada Unión Transitoria.

Que la Unión Transitoria mencionada está conformada en un CINCO POR CIENTO (5 %) por la firma LA RURAL S.A., un VEINTE POR CIENTO (20 %) por la firma OFC S.R.L., en un CINCUENTA Y CINCO POR CIENTO (55 %) por la firma OGDEN ARGENTINA S.A., y el VEINTE POR CIENTO (20 %) restante por la firma ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A.

Que, como consecuencia de la concesión anteriormente mencionada, la Unión Transitoria, tendrá sobre el Centro de Exposiciones y Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires el uso y explotación para el

desarrollo de actividades de gerenciamiento, comercialización, programación y realización de reuniones gubernamentales, seminarios, congresos, conferencias y convenciones.

Que una operación no puede ser objeto de notificación en tanto si bien sobre el inmueble objetó se desarrolló algún tipo de actividad comercial, al momento de la operación, el mismo se encuentra desocupado y sin actividad desde el año 2014, por lo que no puede atribuírsele operación comercial ni clientela alguna.

Que, en el caso en concreto, la citada Comisión Nacional entiende que no se da el requisito de continuidad a fin de considerar notificable una operación económica cuyo principal objeto lo constituya un bien inmueble que tenga clientela propia y continúe utilizándose en la misma actividad que el mismo se venía utilizando.

Que la cuestión planteada no implica una toma de control de una empresa por parte de la Unión Transitoria, en los términos del Artículo 6° de la Ley N° 25.156.

Que la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ha emitido el Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “OPI 297”, donde aconseja al señor Secretario de Comercio disponer que la operación traída a consulta no se encuentra sujeta a la obligación de notificación establecida en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156; asimismo, hacer saber a los consultantes que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente de la referencia, por lo que, si los hechos allí relatados fueran falsos o incompletos, ello tornaría inaplicables los conceptos vertidos en el citado Dictamen.

Que el suscripto comparte los términos del mencionado dictamen al cual cabe remitirse en honor a la brevedad incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN ha tomado la intervención que le compete.

Que el infrascripto resulta competente para el dictado del presente acto en virtud de lo establecido en los Artículos 18 y 58 de la Ley N° 25.156, los Decretos N° 357 de fecha 21 de febrero de 2002 y sus modificaciones, 718 de fecha 27 de mayo de 2016 y la Resolución N° 26 de fecha 12 de julio de 2006 de la ex SECRETARÍA DE COORDINACIÓN TÉCNICA del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA Y PRODUCCIÓN.

Por ello,

EL SECRETARIO DE COMERCIO

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Excéptuase al control previo, establecido en el Artículo 8° de la Ley N° 25.156, la operación traída a consulta por la firma LA RURAL S.A., OFC S.R.L., OGDEN ARGENTINA S.A., ENTRETENIMIENTO UNIVERSAL S.A. UNIÓN TRANSITORIA.

ARTÍCULO 2°.- Hácese saber a la firma consultante que la presente opinión consultiva ha sido emitida valorando como sustento fáctico la descripción realizada en los escritos obrantes en el expediente citado en el Visto, por lo que si los hechos relatados fueran falsos o incompletos, ellos tornarían inaplicables los conceptos allí vertidos.

ARTÍCULO 3°.- Considérase al Dictamen de fecha 26 de enero de 2018, correspondiente a la “OPI 297”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo

desconcentrado en la órbita de la SECRETARÍA DE COMERCIO del MINISTERIO DE PRODUCCIÓN que, como Anexo IF-2018-04644980-APN-CNDC#MP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 4°.- Notifíquese a la firma interesada.

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese y archívese.